



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקח על רישום המקרקעין
פתח תקוה

מס' תיק: 188/08

התובע:

עזרא פישר

ע"י ב"כ עוה"ד אורית גור-

זילברשטיין

מרח' חיים עוזר 31, פתח תקוה

"התובע שכנגד"

-נגד-

הנתבע:

ציון פישר

מרח' קיבוץ גלויות 27, פ"ת

" הנתבע שכנגד "

פסק דין

1. התובע שכנגד והנתבע שכנגד הם אחים המתגוררים בדירות קרקע צמודות ברחוב קיבוץ גלויות 27 בפתח תקוה, מקרקעין הידועים כחלקה 65 בגוש 6328 (להלן-"הבית").
התובעים שכנגד הינן בעלי זכויות בחלקת משנה 6 ואילו הנתבע אינו רשום כבעל זכויות בחלקת משנה 4.

2. התובענה שכנגד הינה למתן הסעדים הבאים :

א. לקבוע כי התובעים זכאים לחזקה ייחודית ולשימוש בלעדי ללא כל הפרעה בשטח החצר המוצמד בפועל לדירתם והמסומן באמצעות הגדר הבנויה.

ב. ליתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבע לעשות שימוש בשטח החצר האמור לעיל ו/או להפריע לתובעים מעשיית שימוש בו, לרבות לפלוש ו/או לספח לעצמו חלקים ממנו.

ג. ליתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבע להרוס באופן חד צדדי את הגדר בין חצרות הצדדים.

ד. ליתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבע להפריע לתובעים בשימוש במחסן אשר בנו ובשימוש בגג שנבנה במסגרת ההרחבה וכן להיכנס ולהתקרב לשטח התובעים ולמה שבנוי עליו, לרבות איסור מעבר בחצר התובעים.

ה. לקבוע כי על הנתבע להזיז לאלתר ועל חשבונו את הגדר שבין חצרות הצדדים כך שלתובעים יוספו עוד שש מ"ר בחצר המוצמדת בפועל לדירתם, כפי שעולה מחוות הדעת מיום 21.8.08.

ו. לאסור על הנתבע המשך שימוש שלא כדין ביחידת הדיור אותה בנה לפני שלש שנים ללא רישיון ואשר בו מתגורר כיום בנו של הנתבע לאחר ששיפץ לצורך כך מחסן (בלתי חוקי אף הוא) שנבנה עוד מתקופת הדייר הקודם ואשר בגינו ניתן בעבר צו הריסה.

ז. לחייב את הנתבע בגין הוצאות שנגרמו לתובעים בגין בניית הגדר מחדש לאחר שהגדר הקודמת נהרסה על ידי הנתבע ביום 16.10.07.

ח. לחייב את הנתבע בתשלום הוצאות התובעים לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק, הוצאות המומחה עורך חוות הדעת, והוצאות בגין עוגמת הנפש אשר נגרמה לתובעים הן בתקופה שקדמה להגשת תביעתו, והן בתקופה שלאחר הגשתה.

3. **התביעה העיקרית נמחקה על ידי על הסף בהחלטה מיום 21.12.08 בין היתר, מן הטעם שח.ל.ד בעלת הזכויות בחלקת משנה 4 לא היתה צד לתביעה.**

4. לטענת ב"כ התובעים שכנגד הנתבע אשר יזם את התביעה המקורית פועל בחוסר תום לב מוחלט. הכח המניע אותו לדבריה הינו יצר נקמנות ושנאה לאחיו וגיסתו (התובעים).

לדבריה, חלוקת החצר נעשתה על פי החלקים המוצמדים לכל דירה, וכן על פי הסכמות ומראה עיניים ולא על ידי מודד מוסמך.

ואף כיום, ולאחר עריכת מדידה, מסתבר, כי הנתבע נטל לעצמו חלק גדול יותר מהרכוש המשותף, על חשבון התובעים, שלהם זכויות קנייניות רשומות.

לטענתה, ביום 26.10.06 ניתן לתובעים היתר לבניית מחסן בצמוד למחסן הנתבע אשר נבנה ללא היתרים. זמן קצר קודם לכן החליט הנתבע להסב את המחסן הלא חוקי שבחצרו ליחידת דיור נפרדת. מתן ההיתר לתובעים הפריע מאוד לנתבע ובמיוחד החלק הנוגע למיקום המחסן, "ומאותו רגע ואילך חלה תפנית חדה ביחסו אל התובעים: הנתבע החל נוהג בתובעים בגסות, בתוקפנות והתלהמות, כאשר הוא מתחיל להתעמר בהם, החל צועק, מקלל וקורא להם בשמות גנאי, תוך שהוא מצהיר קבל עם ועדה כי יגרום להם נזקים, "ילביש עליהם תיקים" ויגרום להם להצטער על התנהגותם כלפיו...".

אשר לגדר נטען, כי "כבר בשנות ה-60 נבנתה על ידי מר עפגון אליעזר, הדייר ממנו רכשו התובעים את דירתם, גדר המפרידה בין שטח החצר שבשימוש לבין שטח החצר שבשימוש השכן דאז...הגדר נבנתה בהתאם להיתר שניתן מטעם עיריית פתח-תקוה לאחר חתימת השכנים על הסכמתם לבניית הגדר, לרבות חתימת בעל הדירה בה מתגורר כיום הנתבע ואשר ממנו רכשה חלד בשלב מאוחר יותר את הדירה...".

לטענתה, מאז ומתמיד היתה גדר מפרידה, כאשר בעבר מדובר היה בגדר רשת ולאחר שהנתבע הרס לראשונה את הגדר שופצה לגדר אבנים.

לסיכום טענה, כי "אמנם לא בוצעה במסגרת הטאבו הצמדה בפועל של החצר המשותפת לכל אחד מבעלי הזכויות (למרות שבנסח הטאבו מצוין מה חלקו של כל בעל זכויות בשטח המשותף) אך לא ניתן להתעלם מהסכמה בפועל של כל דיירי הבניין וההסתמכות שנעשתה בהסתמך על הסכמה זו הכל על פי החלק היחסי המגיע לכל אחד מבעלי הזכויות בדירות בהתאם לגודל הדירה ולזכויות היחסיות שיש להם ברכוש המשותף".

5. הנתבע שכנגד טען, כי התביעה העיקרית הוגשה לאחר שהתובעים החלו בבניית חומת לבנים בחצר הבית.
 בניה זו לטענתו הינה בניה בלתי חוקית, אשר כמותה ביצעו התובעים נוספות.
 באישור העירייה שהוצג טען, כי אין התייחסות לגדר מסוימת ויכול שמדובר בגדר חיצונית לבית.
 מר עפגין חי לדבריו ואף טען, כי תמיד היה קיים מעבר בין הגדרות. לדבריו, התובעים עושים שימוש ייחודי בגג הבית המשותף ואולם הם בוחנים את צעדיהם בהקשר זה.
 בתביעה העיקרית כל מבוקשם היה לאפשר את המעבר בחצר הבית.

6. בנו של הנתבע שכנגד העיד, כי- "הגדר שהייתה קיימת תמיד היתה בגבול אחרת לגמרי ממה שהיא בנויה עכשיו, פנימה יותר לשטח שלהם. שאבא שלי ניסה את הגדר, הוא עשה אותה לפני אותו גבול. תמיד היה שער. אבא שלי אחרי מחלת לב והוא לא בריון. ביום אחד הוצבה חומה ועוד אמרו שיש אישורים מהעירייה, ואמרו זה מה שמגיע לנו, הראו תכנית בנייה, ואמרו שיש אישור שיש חומה. אבי גילה שהשער בניגוד להבטחות נסגר, ולכן שבר את המקום לשער" (ר' פרוטוקול הדיון מיום 11.2.09 בעמ' 9).

7. דיון:

המדובר בבית משותף בן 7 חלקות משנה.
 המחלוקת שבנדון הינה בין בעל זכויות בחלקת משנה אחת בבית לשוכר בחלקת משנה אחרת.
 בביקור שערכתי במקום נוכחתי כי החצר המשותפת בין חלקות משנה 3,4 ו-6 צמודות זו לזו בקירות משותפים ומחולקת בגדרות פנימיים.
 בחצר "של הנתבע שכנגד" שכנגד הוקם מחסן שהוסב כפי הנראה למגורים, אף בצמוד לו בחצר "של התובעים שכנגד" נבנתה יחידה של ממש. התובעים שכנגד בנו אף על גג דירתם.
בנסח הרישום למען הסר ספק לא רשומות הצמודות למי מבעלי הזכויות.

8. זאת ועוד, בדירת התובעים שכנגד רשומה הערה על פי צו בית משפט לעניינים מקומיים פתח תקוה תיק עמק 3199-12-08 מיום 29.1.09.

9. ככלל, בת"א (חיפה) 9063-01 זהבה שולביץ ואח' נ' פנינה קראוס ואח'

תק-של 2008(3), 6303, נקבע לאמור:

"סעיף 31 לחוק המקרקעין קובע כי כל שותף רשאי, בלי הסכמת יתר השותפים, להשתמש במקרקעין המשותפים שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר. לאסיפה הכללית בבית המשותף יש סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף, והיא רשאית להחליט למפרע על הסכמתה לשימוש מיוחד ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' יערי קווינ ואח' פ"ד מ(1), 724).

בהעדר החלטה מסוימת שכזו רשאי, איפוא, כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף שימוש רגיל וסביר לפי תנאי הזמן והמקום כל עוד הוא אינו מונע שימוש דומה מאחרים.

השאיפה צריכה להיות למצוא איזון בין השמירה על הזכויות הקיימות של בעלי הדירות בדירותיהם וברכוש המשותף לבל ייפגעו לבין האינטרס הלגיטימי של כל בעל דירה יחיד לעשות שימוש רגיל ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר.

(ראה: א. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין [חלק שלישי - בתים משותפים, תשס"א - 2001] 102 וכן ראה: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645, (להלן: "פס"ד זמורה"). בהמ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277, נקבע כי התנאים הללו הינם תנאים מצטברים. דהיינו: יש צורך בכך שהשימוש יהא רגיל וסביר, וכן שהשימוש לא ימנע שימוש כזה משותף אחר. שימוש סביר יהא שימוש שיתאם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף. ייעוד החלק של הרכוש המשותף משמע, השימוש בו לפי ייעודו לפי תנאי הזמן, המקום וכוונת בעלי הדירות. כמו כן, נקבע כי בבחינת השימוש יש לבחון גם את תנאי המקום והזמן: תנאי המקום-כלומר המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'), ותנאי הזמן-הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתובה (ראה: עו"ד ע. כהן,

בתים משותפים בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף [תשס"ד-2004], עמ' 48). (ההדגשה שלי ט.ל.)

10. במקרה דנן, לא הובאה החלטה אופרטיבית של האסיפה הכללית אשר להתקנת הגדרות ויש להיזקק, ממילא, לשאלה האם השימוש המתואר, של מי מהצדדים, ברכוש המשותף הינו שימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן והוא אינו מונע שימוש דומה מאחרים.

מה גם שבבית המשותף הרשום כאמור 7 חלקות משנה.

בלשון כבוד השופט ברנזון בע"א 549/73 וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כ"ח(1) 645:

"מובן שהרכוש המשותף כלשונו ולפי הגדרתו שייך לכל בעלי הדירות ונועד לשמש אותם או את מרביתם (סעיף 52 לחוק). משום כך גם ברור, שלא כל בעל דירה יכול לעשות ברכוש המשותף כעולה על רוחו".

11. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים קיימתי ביקור במקום בנוכחותם של הצדדים.

ביקורי במקום היה בבחינת "טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים" מימרה המתבססת על הביטוי התנ"כי: טוב מראה עינים מהלך-נפש (קהלת ו ט).

למגינת לב בביקור במקום נוכחתי, כי הגדרות הבנויות מונעות מעבר חופשי מקצה האחד של הגינה אל הקצה השני. המציאות המתוארת הביאה לכדי כך שעל מנת להגיע לחצר של הנתבע שכנגד, ולהחליף בעת הצורך את בלוני הגז המוצבים שם, יש להוביל את הבלונים דרך הדירה ולצאת מדלת בחדר הילדים.

12. אשר לטענת ב"כ התובעים כי מדובר בהסכמות שניתנו לפני שנים ואף מבוקשה לתקן את התוואי הנוכחי כך שלשטח המוחזק ע"י התובעים דה-פקטו יתווספו 6 מ"ר.

יוער, כי מצב דברים שבו תופס בעל דירה חזקה בחלק חצר הבית המשותפת, מבלי שהזכויות הוגדרו בחוזה העברת זכויות מפורש, ניתן להיחזות כמצב של רשות, וגם אם ההרשאה אינה מפורשת יכולה שתיקת שאר בעלי הדירות להתפרש כהרשאה שבשתיקה.

ואולם, משלא הוכח כאמור שניתנה **תמורה**, עסקינן בהרשאת חינם, לגביה נפסק כי ניתן לבטלה, עם גילוי דעתו של בעל דירה אחר, שאף לו חלק בחצר המשותפת, שאין ברצונו להמשיך, ואף אין מניעה שהודעת הביטול תינתן בתביעת פינוי, כגון זו שבפני, ר' בספרו של פרופ' מיגל דויטש "קניין" כרך ב' עמוד 414 ואילך והאסמכתאות שם.

13. זאת ועוד, בהקשר זה של תפיסת חזקה ברכוש המשותף, פסק הדין המנחה ניתן ברע"א 6339/97 **משה רוקר ואח' נ. משה סלומון ואח'**, תק-על 99 (4), תשנ"ט - תש"ס 1999.

בפסק דין זה עמד כבוד השופט טירקל על מעמדן של זכויות הקניין, אשר במקרה דנן שייכות כאמור לכלל בעלי הדירות, בהקשר זה נפסק, כי-

"השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי-משני בחשיבותו לקודמיו-הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי הדין. לענין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמא, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול דעתו של בית המשפט, עד בלי השאיר לו שריד."

פסק דין נוסף בסוגיה ניתן בע"א (תל אביב - יפו) 2816/03 **ציפורה קונצ'צקי ואח' נ. דליה שפלן ואח'** תק-מח 2006 (2), 991, שם הורה בית משפט מחוזי על סילוק ידם של בעלי דירה שהחזיקו בגג הבית המשותף למעלה מ-40 שנה, לאחר שקיבלוהו מידי הקבלן שבנה את הבית. בית המשפט פסק שם כי הואיל והגג לא הוצמד לדירתם, מהווה שתיקת שאר בעלי דירות הבית רישיון גרידא, שניתן להפסיקו בכל עת.

14. הצדדים לתביעה הם אחים. התמונות שהוצגו בפני מעידות על כך שבעבר ככל שהוצבו גדרות **היו שערים באותן גדרות** שאפשרו מעבר חופשי מחצר לחצר.

בתמונות נראים, על פי עדויות הצדדים, בני הדודים בניו ובנותיו של התובע והנתבע משחקים באין מפריע. ברבות הימים הוסלמו היחסים השערים נעלמו/כוסו והגדרות לבשו שלמת בטון והפכו מגדרות ברזל לגדר בנויה עד שאין יוצא ואין בא בה.

15. אמנם, התביעה העיקרית שהביאה כפי הנראה להגשת תביעה זו החלה ברצונו של הנתבע שכנגד לאפשר מעבר בין החצרות, בין היתר, להובלת בלוני גז תביעה שנדחתה כאמור גם מן הטעם שאינו בעל זכויות רשום בבית.

ואולם, אף שהתביעה העיקרית נמחקה נותרה התביעה שבנדון בה מבוקש ליתן גושפנקא ולמעשה **להצמיד הלכה למעשה לדירת התובעים שכנגד את החלקים ברכוש המשותף, אשר הם עושים בהם שימוש ייחודי.**

ברי, כי בנסיבות המתוארות אין להתיר למי מהצדדים שימוש ייחודי ברכוש המשותף.

16. יוער, כי אשר להיתר הבניה-ככל שישנו (ר' ההערה בנסח הרישום המתוארת)- נראה כי אין להיתר זה כל נפקות קניינית, שכן חוק התכנון והבניה והוראותיו אינם דנים בזכויות הקנייניות המושגיות של הנוגעים בדבר אלא בזכויות במישור התכנון בלבד (בג"צ 305/82 **מור נ' הועדה המחוזית**, פ"ד לח (1) 141). לפיכך, אף קיומו של היתר בנייה אין בו, כשלעצמו, כדי להכשיר בנייה הפוגעת לכאורה בזכותם הקניינית של בעלי הדירות האחרים, ברכוש המשותף (ר' רע"א 6339/97 **משה רוקר ואח' נ. משה סלומון ואח'**, תק-על 99 (4), וכן ת"א (מחוזי ת"א) 2498/04 **לוי גליה נ' עז' טואש זאב ז"ל** (לא פורסם)).

17. בנסיבות המקרה, מצאתי לצטט את קביעתו של כב' הנשיא שמגר בהטיבו להגדיר את אופי היחסים בין בעלי זכויות בבית, יפים הדברים אז ויפים הם גם בענייננו-

"סכסוכים בין בעלי דירות לגבי השימוש ברכוש המשותף ולגבי ניהול הבית המשותף הם סכסוכים נפוצים. על המאפיינים המיוחדים של "יחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף" עמד בתוארו אז כבוד הנשיא מ' שמגר באומרו:

"יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות, עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקרבה פיסית הדוקה בין הצדדים --- המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 יוסף טרופקי ואח' נ' אלפונסו דיין ואח', פ"ד מו(5) 454).

אם נאים הדברים בין אנשים זרים נאים הם פי כמה וכמה בין בני משפחה הדרים זה בצמוד לזה.

18. מכל האמור, אין לי אלא לדחות את התביעה על כל מרכיביה, אין לבקשה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף- בנסיבות המקרה- כל יסוד בדין.

למעלה מן הצורך יוער, כי אף לא תיתכן קביעה שיפוטית בהקשר זה בהעדר יתר בעלי הזכויות בבית ובהעדר הבעלים הרשומים של הדירה המצויה בשכירות על ידי הנתבע שכנגד ודי אף בכך כדי לדחות את התביעה.

כל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן בהעדר הצדדים.

היום ו' אייר תשס"ט

30 אפריל 2009.

טלי להב

המפקחת על רישום המקרקעין